

1507752-24.2021.8.26.0127

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... a traçar uma política de combate ao tráfico de entorpecentes. Afirmar que a saúde pública não se vê em risco, ou ainda, que o seu uso não tem potencialidade lesiva a terceiros, é olhar para o consumo dissociado do mundo que o sustenta. Armas. Mortes. Facções. Permitir o consumo, sem se preocupar com a forma com que a droga chega ao consumidor, é um contra senso. Nem se diga que é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1507752-24.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507752-24.2021.8.26.0127

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MIRIA DE MORAES CALANDRIN

Juiz de Direito: Dr. PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Vistos, etc.

MIRIA DE MORAES CALANDRIN foi denunciada pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 17:10 horas, na Rua Natal, nº 33, Corintinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, guardava, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, totalizando o peso de 3,5 gramas 3, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi regularmente citada e intimada, e, em audiência de Instrução e Julgamento realizada nesta data, foi recebida denúncia, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas, e, ao final, a acusada foi interrogada.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal ao passo que a Defesa pugnou pela menor pena possível.

É o relatório.

Decido.

O artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 é constitucional.

Como fundamento para minha decisão, trago à colação o seguinte julgado: Apelação.

Crime. Posse de entorpecente. Uso próprio. Art. 28 da Lei nº

11.343/06. Constitucionalidade da norma Tipicidade reafirmada. Lesividade social.

Ínfima Quantidade. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Periculosidade

Social da Ação. Ausência de Adequação Social. Perigo Abstrato ou Presumido. Improvido o recurso. Prescrição. Extinção. VOTO DA CONSTITUCIONALIDADE. 1- Inconstitucionalidade, ainda, não declarada, integra o dispositivo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 o ordenamento jurídico, objetivando atender o próprio texto constitucional que se obriga a traçar uma política de combate ao tráfico de entorpecentes. Afirmar que a saúde pública não se vê em risco, ou ainda, que o seu uso não tem potencialidade lesiva a terceiros, é olhar para o consumo dissociado do mundo que o sustenta. Armas. Mortes. Facções. Permitir o consumo, sem se preocupar com a forma com que a droga chega ao consumidor, é um contra senso. Nem se diga que é frágil dizer que o usuário fortalece o tráfico. A assertiva nada mais é do que um princípio da economia de mercado. É o que se vê no capitalismo. O mercado cresce porque há consumo. E mais consumo, fortalece a base do fornecedor. O consumo fortalece a fonte de qualquer produto. Em todos os tempos foi assim. E nem se diga que o Estado Brasileiro deveria fornecer o entorpecente em um país que muitos passam fome e morrem por não haver atendimento hospitalar chega a ser bizarro pensar em uma rede de fornecimento de maconha ou cocaína em praça pública. Infelizmente, não vivemos na Holanda. Em regra, a droga gera a perda da capacidade produtiva. Foi empregada e, ainda, é como meio de dominação. Vicia. Cria dependência. Essa, sim, uma constatação que não vem dos corredores dos fóruns mas da história mundial. E degradação não tem classes sociais. 2- Afirmar que a solução punitiva e uma "política de guerra" as drogas não tem se mostrado eficiente para reduzir o tráfico não é o bastante. E se o sistema não se mostra eficiente para recuperar o assassino, solta-se? Nunca soubemos que a política de criminalização dos homicídios também tenha reduzido o número de mortes em nosso país. E se o sistema não se mostra eficiente para recuperar o usuário, se destrói o sistema? Evidente que não. Modifica-se. E foi exatamente esse o sentido do advento do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Um dos poucos instrumentos que o Estado tem para alcançar o viciado. As famílias já não mais querem e nem parecem ter força econômica - este é um fator em alteração - para lutar pela recuperação de seus dependentes. E muitas chegam - pais, irmãos, tios querendo saber o que magistrado pode fazer para ajudá-los com o dependente. 3- Típica a conduta. Não há como se afirmar que a hipótese se restringe a autolesão. O uso repercute na desordem social e familiar. A autolesão não é, realmente, punida em nosso ordenamento, mas, daí, a afirmar que a ausência de consciência proporcionada pelo consumo do entorpecente se restringe a lesividade, apenas, do consumidor, é esquecer os efeitos nocivos produzidos em cadeia pela droga, na sociedade. Clama-se pela proibição e criminalização da comercialização de produtos danosos à saúde, de alimentos vencidos, da veiculação de propaganda enganosa ao público. Clama-se que o Estado, dê melhores condições de vida aos seus cidadãos, mas, nunca se indaga, quanto custa este consumo desenfreado da droga à sociedade. Diversos projetos são desenvolvidos pela União, pelos Estados e Municípios para o atendimento de drogados. Centros de Atendimentos - CAP's - estão funcionando com sucesso no Rio de Janeiro. Em quase todos os Postos de Atendimento Médico do Município - PAM's - existe uma equipe interdisciplinar para o atendimento de viciados. Internações são proporcionadas pelo Estado - muito embora, poucas as vagas - para o atendimento de dependentes. Projetos caros são desenvolvidos. E, quase sempre, preveem a disposição do drogado, um clínico, um psicólogo, um psiquiatra, uma assistente social e o próprio fornecimento de medicamentos. Equipes multidisciplinares são formadas, tão somente, para o atendimento do viciado, inclusive, se fazem presentes, mensalmente, nos próprios Juizados Especiais. Milhões são gastos na saúde. Avós, pais e irmãos recorrem ao Judiciário, vítimas de violência doméstica praticada por drogados. Infundáveis "coações morais são exercidas sobre os provedores" dos usuários para que se mantenham estes no vício. Roubos e furtos crescem na mesma proporção do crescimento do tráfico de drogas. Indivíduos nada produtivos são gerados e mantidos sem emprego porque a droga atinge - repita-se - a sua capacidade produtiva. Há um custo social alto. Precisa-se evitar o vício pernicioso. E os bens públicos precisam ser assegurados. Entendo ofensivo o consumo à sociedade. DA AUSENCIA DE INSIGNIFICÂNCIA. 4- Insuscetível, igualmente, o Princípio da Bagatela. Elaborado, inicialmente, por Welzel ao analisar o Princípio da Adequação Social e a existência

de lesões ao direito que estariam excluídas da incidência da norma jurídica, por força da sua insignificância, vamos observar a adoção deste princípio como um retrato da idéia de que o direito não deve se ocupar de bagatelas. Justifica-se a proteção realizada pelo Direito Penal - de acordo com este princípio - até o momento em que se vislumbra a necessidade de se resguardar o bem jurídico. Ausente a possibilidade de lesão, não há que se verificar a sua incidência. A conduta de quem "usa substância entorpecente" é incriminada não só com vista ao risco da saúde de quem a adquire, mas, igualmente, objetivando elidir - como já dissemos - o risco social. É certo, ainda, que quem a adquire o faz movimentando uma rede de fornecimento que, indubitavelmente, põe em risco a sociedade, o próprio Estado. Pretendeu-se, sim, - em verdadeira Exceção Pluralística a Teoria Monista - penalizar de forma mais branda o que faz uso de substância entorpecente, em razão da sua menor periculosidade. Da mesma forma, que poderia optar o Legislador pela descriminalização de citada conduta, deixando de lhe prever alguma sanção. A exclusão do tráfico exige - repita-se, a repressão da sua fonte de ser, qual seja, o consumo. Eis a razão de não ter se preocupado o Legislador em fixar quantias precisas para a configuração dos tipos prescritos, limitando-se a exigir que se encontre o agente na posse de substância entorpecente ou que possa determinar a dependência, sem que se afira em concreto a lesividade no agente que a pretende. Acresça-se ter sido atendido o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ao ser observado "a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem com a conduta e os antecedentes do agente". Pontue-se ter sido reconhecida a quantidade e natureza, exatamente, para determinar a conduta como de uso e não de tráfico, sendo certo que as circunstâncias e os antecedentes determinaram a fixação da medida eleita. Não há como afirmar, portanto, violada a norma do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e do art. 5º, inc. XXXV da Constituição da República. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. 5- O direito a inviolabilidade da intimidade e da vida privada - contidos no art. 5º, inc. X da Constituição da República - não é absoluto, quando do outro lado temos uma ameaça social. Nem há como afirmar haver afronta aos princípios da igualdade e da dignidade humana, ante os demais princípios afeitos a segurança da coletividade. Íntegros os princípios do art. 5º, inc. I, X e XIII da Constituição da República. DA AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE. 6- O Supremo Tribunal Federal não alterou o seu posicionamento. E reiteradas são as decisões que reafirmam a tipicidade da conduta. O Recurso Extraordinário 635659/SP - em que se reconheceu a Repercussão Geral - não foi objeto de decisão final, portanto, não vinculante. DA PRESCRIÇÃO. 7- Em vista do transcurso do lapso temporal de mais de um ano entre a data do fato (04.11.12) e a presente, sendo certo se reduzir o prazo de dois previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/06, a metade, porque era o Réu menor de 21 anos à época dos fatos, a luz do art. 115 do Código Penal, impõe-se, a mingua de marcos interruptivos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. CONCLUSÃO. 8- Voto no sentido de conhecer do recurso, e, no mérito negar-lhe provimento, na medida em que, a despeito da tipicidade, reconhecida por maioria, impõe-se de ofício, ante a incidência da prescrição, a declaração da extinção da punibilidade. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014. Cláudia Márcia Gonçalves Vidal Juíza de Direito. Welzel, Hans. "Das deutsche Strafrecht", Aufl. Berlin, Walter de Gruyter, ano 69, p.56. 2 EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. (TJ-RJ - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 00241760320128190007 RJ 0024176-03.2012.8.19.0007)

Também não há que se aplicar ao caso o princípio da insignificância ainda que a quantidade da droga apreendida tenha sido mínima.

Nesse sentido: (...) 2. Inaplicável o Princípio da Insignificância ao delito de uso de entorpecentes, tendo em vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo totalmente irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes desta Corte de do Supremo

Tribunal Federal (...). (STJ - RHC 22372/ES, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz - DJ. 15/12/2009 - DP. 08/02/2010). TÓXICO - USUÁRIO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO - INADMISSIBILIDADE - COMPORTAMENTO SOCIALMENTE REPROVÁVEL - 'NOVATIO LEGIS IN MELIUS' - PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE - POSSIBILIDADE. 1. Não se aplicam aos delitos de tóxicos, o princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato, ainda que a quantidade de droga apreendida seja ínfima, pois além de serem crimes de perigo abstrato e presumido, a norma visa tutelar bem jurídico maior, a saúde pública, sendo certo que os malefícios causados pela disseminação do uso de drogas afetam não só o usuário em particular, mas a sociedade como um todo. 2. Não prevendo a nova Lei Antidrogas pena privativa de liberdade para usuários de drogas, sendo, portanto, mais benéfica, tem aplicação imediata e retroage para beneficiar o agente (no art. 5.º, XL, da CF e no art. 2.º § único, do CP). 3. Recurso parcialmente provido (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.02.013635-1/001, 3ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Antonio Armando dos Anjos - DJ. 29/05/2007 - DP. 27/06/2007). No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade restou demonstrada pelo Laudo pericial de fls 08/14. Do mesmo modo ficou provada a autoria. As testemunhas, Rosana Poyares e Rogerio Ferrari, confirmaram que com a acusada foram encontradas duas porções de cocaína. A ré em seu interrogatório confessou a prática delitiva. Assim, como as provas estão de acordo com os fatos narrados na denúncia, a procedência da ação é medida que se impõe. Autorizada a condenação, passo ao cálculo da pena. Na primeira fase, não há elementos a serem considerados. Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência, fls. 22, e a atenuante da confissão. Não há causas de aumento ou de diminuição na terceira fase de aplicação de pena. Assim, fixo a reprimenda em cinco meses de prestação de serviços à Comunidade. Desse modo, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06, aplico a pena de cinco meses de prestação de serviços a comunidade. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MIRIA DE MORAES CALANDRIN incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de cinco meses de prestação de serviços a comunidade, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação. Com o trânsito em julgado da decisão, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, expeça-se carta de guia definitiva e, certidão de Honorários Advocatícios à Douta Patrona da ré. Custas na forma da lei P.I.C.

Carapicuíba, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA